

1500669-05.2022.8.26.0617

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: CARLOS GUTEMBERG DE SANTIS CUNHA

Comarca: São José dos Campos

Foro: Foro de São José dos Campos

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 10/10/2022

... tal como ocorre, na maioria das vezes, com o tráfico de drogas.

Não é das guardas municipais, mas sim das polícias, como regra, a competência para patrulhar supostos pontos de tráfico de drogas, realizar abordagens e revistas em indivíduos suspeitos da prática de tal crime ou ainda investigar denúncias anônimas relacionadas ao tráfico e outros delitos cuja prática ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José dos Campos

Foro de São José dos Campos

4ª Vara Criminal

Av. Salmão, 678, São José dos Campos - SP - cep 12246-260

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500669-05.2022.8.26.0617 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500669-05.2022.8.26.0617 - Controle nº 2022/000486

Classe - Assunto

Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

VICTOR FRANCO MACHADO ROSA

Justiça Gratuita

Réu Preso

Juiz(a) de Direito: CARLOS GUTEMBERG DE SANTIS CUNHA

Vistos.

VICTOR FRANCO MACHADO ROSA, já qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no delito capitulado no artigo 33, "caput", e 35, "caput", ambos na companhia do adolescente K. F. S. R., razão pela qual também está respondendo pela causa de aumento prevista no art. 40, VI, também da Lei 11.343/06, porque no dia 17 de maio de 2022, por volta das 09h55, na av. dos Evangélicos, altura do nº 1732, Campo dos Alemães, em São José dos Campos, agindo em concurso com o adolescente, de 16 anos, e com outros agentes não identificados, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, trazia consigo 15 porções de crack, subproduto da cocaína, 45 porções de maconha e 26 porções de cocaína para fins de tráfico. O acusado associou-se ao adolescente e a outros agentes não identificados para o fim de praticar, reiteradamente ou não, crimes previstos no artigo 33 da Lei de Drogas. Segundo apurado, os dois pertenciam ao grupo criminoso que controla o tráfico de drogas na avenida dos Evangélicos, Campo dos Alemães, em São José dos Campos. De acordo com a distribuição de tarefas do grupo, o denunciado ficava em posse das

drogas e atendia os compradores, enquanto o adolescente ficava com a guarda do dinheiro auferido.

Na manhã dos fatos, guardas municipais em diligências pelo bairro notaram a atuação do acusado que estava numa bicicleta, tinha uma sacola na mão e correu para escondê-la no buraco de um muro quando viu a viatura. Realizaram a abordagem do acusado e do adolescente. Com o adolescente havia R\$ 194 em espécie, oriundos da venda das drogas. No buraco do muro estava a sacola escondida pelo acusado. Dentro dela havia 15 porções de crack, subproduto da cocaína, 45 porções de maconha e 26 porções de cocaína.

Após o oferecimento da denúncia, o acusado, notificado, apresentou defesa prévia. Recebida a exordial, o acusado foi citado e, em juízo, durante a instrução, testemunhas foram inquiridas.

O acusado, após, foi interrogado.

Em memoriais, o Ministério Público pugnou pela procedência da ação penal, porquanto autoria e materialidade restaram demonstradas. A atuação da guarda municipal foi legal porque o local é conhecido como sendo de tráfico de droga.

A defesa requereu a absolvição do réu eis que há nulidade decorrente da ilegal ação da guarda municipal; não há prova estivesse envolvido com o tráfico; não estava associado ao menor; por fim, formulou pedidos alusivos à dosimetria da pena, regime inicial, multa e apelo em liberdade.

Relatei.

Decido.

A ação improcede.

Vejamos.

Como é cediço, para que se faça possível a decisão condenatória, dois requisitos se mostram absolutamente necessários, sem os quais impõe-se a absolvição.

Primeiro deve estar provada a materialidade, que, in casu, qualquer dúvida resta ante a análise do boletim de ocorrência, autos de exibição, apreensão, constatação provisória e laudo toxicológico definitivo, todos carreados.

Resta o segundo, autoria, isto é, ter a real certeza de que o sujeito ativo praticou o fato descrito na norma penal incriminadora.

Neste ponto, prova não há.

Com efeito.

Interrogado na fase policial negou os fatos. Disse que trabalha como pizzaiolo, mora com os pais. Estava preso por tráfico de drogas, mas saiu recentemente da prisão. Afirmou que estava no local, de bicicleta, para adquirir uma bucha de maconha para seu próprio consumo, uma vez que é viciado nesta droga, quando foi abordado pelos guardas civis. Nega que tenha tentado fugir e que estivesse na posse de sacola contendo drogas ou que a tivesse escondido no buraco existente no muro. Quando foi abordado, nada de ilícito foi encontrado com o interrogado, nem mesmo dinheiro. Indagado como pretendia comprar drogas para seu próprio consumo, já que não estava com dinheiro, afirma que já havia pago R\$ 5,00 para um traficante do local. Conhece o adolescente do bairro, desde a infância, e que também não viu ele vendendo drogas.

Em juízo novamente negou. Disse que a droga não lhe pertencia e que nada colocou no muro.

Já os guardas municipais foram ouvidos e afirmaram que realizaram a abordagem do acusado porque estava colocando uma sacola em um muro. Não sabiam se estava ocorrendo o tráfico. Achavam que sim em razão do local. Retornando ao local onde foi deixada a sacola, o buraco no muro, verificaram que na sacola havia entorpecentes. Não se recordam como o menor acabou sendo envolvido.

Ocorre que a Guarda Municipal não poderia, na hipótese, realizar a abordagem do acusado posto inexistir, ante ao que se desenhou, a figura do flagrante indubitado, ao contrário.

Conforme exposto pelos próprios guardas, o acusado foi abordado em razão de encontrar-se em "atitude suspeita".

Assim decidiu o S.T.J., no Recurso Especial 1977119.

"RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ATUAÇÃO DAS GUARDAS MUNICIPAIS. BUSCA PESSOAL. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO CLARA, DIRETA E IMEDIATA COM A TUTELA DOS BENS,

SERVIÇOS E INSTALAÇÕES MUNICIPAIS. IMPOSSIBILIDADE. PROVA ILÍCITA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 157 E 244 DO CPP. RECURSO PROVIDO.

A Constituição Federal de 1988 não atribui à guarda municipal atividades ostensivas típicas de polícia militar ou investigativas de polícia civil, como se fossem verdadeiras “polícias municipais”, mas tão somente de proteção do patrimônio municipal, nele incluídos os seus bens, serviços e instalações. A exclusão das guardas municipais do rol de órgãos encarregados de promover a segurança pública (incisos do art. 144 da Constituição) decorreu de opção expressa do legislador constituinte – apesar das investidas em contrário – por não incluir no texto constitucional nenhuma forma de polícia municipal. 2.

Tanto a Polícia Militar quanto a Polícia Civil – em contrapartida à possibilidade de exercerem a força pública e o monopólio estatal da violência – estão sujeitas a rígido controle correcional externo do Ministério Público (art. 129, VII, CF) e do Poder Judiciário (respectivamente da Justiça Militar e da Justiça Estadual). Já as guardas municipais – apesar da sua relevância – não estão sujeitas a nenhum controle correcional externo do Ministério Público nem do Poder Judiciário. É de se ver com espanto, em um Estado Democrático de Direito, uma força pública imune a tais formas de fiscalização, a corroborar, mais uma vez, a decisão conscientemente tomada pelo Poder Constituinte originário quando restringiu as balizas de atuação das guardas municipais à vigilância do patrimônio municipal.

Não é preciso ser dotado de grande criatividade para imaginar – em um país com suas conhecidas mazelas estruturais e culturais – o potencial caótico de se autorizar que cada um dos 5.570 municípios brasileiros tenha sua própria polícia, subordinada apenas ao comando do prefeito local e insubmissa a qualquer controle externo. Ora, se mesmo no modelo de policiamento sujeito a controle externo do Ministério Público e concentrado em apenas 26 estados e um Distrito Federal já se encontram dificuldades de contenção e responsabilização por eventuais abusos na atividade policial, é fácil identificar o exponencial aumento de riscos e obstáculos à fiscalização caso se permita a organização de polícias locais nos 5.570 municípios brasileiros.

A exemplificar o patente desvirtuamento das guardas municipais na atualidade, cabe registrar que muitas delas estão alterando suas denominações para “Polícia Municipal”. Ademais, inúmeros municípios pelo país afora – alguns até mesmo de porte bastante diminuto – estão equipando as suas guardas com fuzis, equipamentos de uso bélico, de alto poder letal e de uso exclusivo das Forças Armadas.

A adequada interpretação do art. 244 do CPP é a de que a fundada suspeita de posse de corpo de delito é um requisito necessário, mas não suficiente, por si só, para autorizar a realização de busca pessoal, porque não é a qualquer cidadão que é dada a possibilidade de avaliar a presença dele; isto é, não é a todo indivíduo que cabe definir se, naquela oportunidade, a suspeita era fundada ou não e, por consequência, proceder a uma abordagem seguida de revista. Em outras palavras, mesmo se houver elementos concretos indicativos de fundada suspeita da posse de corpo de delito, a busca pessoal só será válida se realizada pelos agentes públicos com atribuição para tanto, a quem compete avaliar a presença de tais indícios e proceder à abordagem do suspeito.

Ao dispor no art. 301 do CPP que “qualquer do povo poderá [...] prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito”, o legislador, tendo em conta o princípio da autodefesa da sociedade e a impossibilidade de que o Estado seja onipresente, contemplou apenas os flagrantes visíveis de plano, como, por exemplo, a situação de alguém que, no transporte público, flagra um indivíduo subtraindo sorrateiramente a carteira do bolso da calça de outrem e o detém. Diferente, porém, é a hipótese em que a situação de flagrante só é evidenciada após realizar atividades invasivas de polícia ostensiva ou investigativa como a busca pessoal ou domiciliar, uma vez que não é qualquer do povo que pode investigar, interrogar, abordar ou revistar seus semelhantes.

Da mesma forma que os guardas municipais não são equiparáveis a policiais, também não são cidadãos comuns. Trata-se de agentes públicos com atribuição sui generis de segurança, pois, embora não elencados no rol de incisos do art. 144, caput, da Constituição, estão inseridos § 8º de tal dispositivo; dentro, portanto, do Título

V, Capítulo III, da Constituição, que trata da segurança pública em sentido lato. Assim, se por um lado não podem realizar tudo o que é autorizado às polícias, por outro lado também não estão plenamente reduzidos à mera condição de "qualquer do povo"; são servidores públicos dotados do importante poder-dever de proteger o patrimônio municipal, nele incluídos os seus bens, serviços e instalações. É possível e recomendável, dessa forma, que exerçam a vigilância, por exemplo, de creches, escolas e postos de saúde municipais, de modo a garantir que não tenham sua estrutura física danificada ou subtraída por vândalos ou furtadores e, assim, permitir a continuidade da prestação do serviço público municipal correlato a tais instalações. Nessa esteira, podem realizar patrulhamento preventivo na cidade, mas sempre vinculados à finalidade específica de tutelar os bens, serviços e instalações municipais, e não de reprimir a criminalidade urbana ordinária, função esta cabível apenas às polícias, tal como ocorre, na maioria das vezes, com o tráfico de drogas.

Não é das guardas municipais, mas sim das polícias, como regra, a competência para patrulhar supostos pontos de tráfico de drogas, realizar abordagens e revistas em indivíduos suspeitos da prática de tal crime ou ainda investigar denúncias anônimas relacionadas ao tráfico e outros delitos cuja prática não atinja de maneira clara, direta e imediata os bens, serviços e instalações municipais. Poderão, todavia, realizar busca pessoal em situações absolutamente excepcionais - e por isso interpretadas restritivamente - nas quais se demonstre concretamente haver clara, direta e imediata relação de pertinência com a finalidade da corporação, isto é, quando se tratar de instrumento imprescindível para a tutela dos bens, serviços e instalações municipais. Vale dizer, só é possível que as guardas municipais realizem excepcionalmente busca pessoal se houver, além de justa causa para a medida (fundada suspeita de posse de corpo de delito), relação clara, direta e imediata com a necessidade de proteger a integridade dos bens e instalações ou assegurar a adequada execução dos serviços municipais, o que não se confunde com permissão para realizarem atividades ostensivas ou investigativas típicas das polícias militar e civil para combate da criminalidade urbana ordinária.

Na hipótese dos autos, os guardas municipais estavam em patrulhamento quando depararam com o recorrente sentado na calçada, o qual, ao avistar a viatura, levantou-se e colocou uma sacola plástica na cintura. Por desconfiar de tal conduta, decidiram abordá-lo e, depois de revista pessoal, encontraram no referido recipiente certa quantidade de drogas que ensejou a prisão em flagrante delito. Ainda que eventualmente se considerasse provável que a sacola ocultada pelo réu contivesse objetos ilícitos, não estavam os guardas municipais autorizados, naquela situação, a avaliar a presença da fundada suspeita e efetuar a busca pessoal no acusado. Caberia aos agentes municipais, apenas, naquele contexto totalmente alheio às suas atribuições, acionar os órgãos policiais para que realizassem a abordagem e revista do suspeito, o que, por não haver sido feito, macula a validade da diligência por violação do art. 244 do CPP e, por conseguinte, das provas colhidas em decorrência dela, nos termos do art. 157 do CPP, também contrariado na hipótese. Recurso especial provido. "

Aliás, ao contrário do exposto pelo Ministério Público, tanto não havia certeza da existência do crime quando da abordagem que os próprio guardas municipais neste sentido se manifestaram.